

1502935-76.2020.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275

Magistrado: FABIANO DA SILVA MORENO

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública. 5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502935-76.2020.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502935-76.2020.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CAROLINE PASTOR VICENTE e outro

Juiz de Direito: Dr. FABIANO DA SILVA MORENO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CAROLINE PASTOR VICENTE, qualificada às fls. 10 e 67, como incurso no artigo 273, § 1º-B, incisos I, II, III, IV, V e VI.

Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de fevereiro de 2020, às 09h30min, na rua Etelvina Teixeira da Silva, nº 362, nesta cidade e Comarca de Marília-SP, CAROLINE PASTOR VICENTE, qualificada às fls. 10 e 67, tinha em depósito para vender, produto sem registro, sendo exigível, no órgão de vigilância sanitária; sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; de procedência ignorada; e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade competente.

Ao que se apurou, a denunciada guardava em sua residência, para o fim de venda, 23 (vinte e três) frascos contendo cápsulas com substância, cujo rótulo indicava tratar-se de produto denominado Fat Red Burner; 1 (um) frasco contendo cápsulas com substância, cujo rótulo indicava tratar-se de produto denominado Fat Burning Power; 21 (vinte e um) frascos contendo cápsulas com substância, cujo rótulo indicava tratar-se de produto denominado Fat Burning Power; 1 (um) frasco contendo cápsulas com substância, cujo rótulo indicava tratar-se de produto denominado Emagry Max (fls. 5/6).

Nas circunstâncias de tempo e local acima, os produtos foram apreendidos por Policiais Civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão.

Inquirida, a denunciada admitiu que, como autônoma, há um ano comercializava os produtos ditos emagrecedores Fat Burning Power, Fat Red Burner e Emagry Max. Ademais, indicou a pessoa de que supostamente comprava e receberia os produtos, pessoa física (fls. 10). Os produtos foram submetidos à exame pericial pelo Instituto de Criminalística, que assim os descreveu (fls. 23/24):

"(...).

A) 01 (um) frasco de plástico branco, de tampa plástica na cor branca, lacrado, apresentando rótulo de cor vermelha, apresentando as inscrições "FAT RED BURNER", "Não é vendido na internet", "30 cápsulas", "Válido por 2 anos a partir de JULHO/2019"; "Composição: Fucus, Carquejo Doce, Espinheira Santa, Spirulina, Gelatina, Sene, Alfafa, Bardana e Chá Verde". Apresentava ainda no rótulo sugestões de uso, contra-indicações e a inscrição: "Produto Fitoterápico isento de registro, Art. 28 Decreto 79094 de 05/01/1977 - Lei 6360".

(...)

B) 01 (um) frasco de plástico branco, de tampa plástica de rosquear na cor vermelha, lacrado, apresentando rótulo de colorido com as inscrições "EMAGRY MAX - Ultra Concentrado", "Composto Natural - Reeducador alimentar", "Produto unissex", "60 cápsulas", "LOTE: EM 0024", "FAB: 06/2019", "VAL: 06/2021" "Composição - Cada cápsula de 450mg contém: Boldo do chile (50mg), Carqueja (50mg), Fucus (100mg), Agar agar (50mg), Quitosana (100mg), Sene (50mg), Espinheira santa (50mg)". Apresentava ainda no rótulo sugestões de uso e a inscrição: "PRODUTO FITOTERÁPICO ELABORADO DE ACORDO COM A FARMACOPÉIA BRASILEIRA", "Isento de Reg. de acordo com a resolução nº 23 de 15/03/2000, de Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA";

(...).

C) 21 (vinte e um) frascos de plástico branco, de tampa plástica de rosquear na cor lilás, lacrados, apresentando rótulo colorido com as inscrições "FAT BURNING POWER - Emagreça sem segredo", "IV Nutri Emagrecedor", "30 cápsulas", "LOTE: EM 0022", "FAB: 07/2019", "VAL: 07/2021", "Composição: Fibra de Polissacarídeo, Fucus, Spirulina, Colágeno, Peptiplus Sene, Óleo Vera, Agar agar, Fibra, Psyllium, Plantago, Ovata, Picolinato de cromo". Apresentava ainda no rótulo sugestões de uso, restrições e a inscrição: "PRODUTO FITOTERÁPICO ELABORADO DE ACORDO COM A FARMACOPÉIA BRASILEIRA", Isento de Reg. de acordo com a resolução nº 23 de 15/03/2000, Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA". Os frascos estavam acondicionados em 1 caixa de papelão contendo adesivo de identificação "SEDEX" e código de rastreamento "OD 76580451 9 BR".

Nas análises químico-farmacêuticas, a perícia obteve os seguintes resultados (fls. 35/36):

"(...).

Item A: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA e CAFEÍNA

Item B: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA, SIBUTRAMINA e DIAZEPAM

Item C: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA e SIBUTRAMINA.

(...)"

Consignou o laudo pericial, ainda, que "Nenhum dos frascos examinados apresentava indicação de fabricante ou número do responsável junto ao Conselho Regional de Farmácia" (fls. 36).

Considerou, ainda, a perícia, que HIDROXICLOROTIAZIDA é uma substância diurética, que acaba por favorecer a eliminação de líquidos do organismo; CAFEÍNA é um estimulante do sistema nervoso central, provocando aceleração do metabolismo; SIBUTRAMINA é um inibidor de apetite, cujo consumo eleva a sensação de saciedade; DIAZEPAM é uma substância ansiolítica, capaz de diminuir a tensão psíquica (fl. 41).

A Anvisa informou que os produtos apreendidos não são registrados naquele órgão e as substâncias nele encontradas são classificadas como sujeitas a controle, devem ser guardadas sob responsabilidade de farmacêutico ou químico responsável pelo controle dos produtos e vendidas mediante prescrição médica, com retenção da receita pela farmácia ou drogaria (fls. 100/102).

Autos em apenso nº 1500380-86.2020. 8.26.0344

Relatório de investigação às fls. 02/03.
Mandado de busca e apreensão às fls. 13.
Boletim de ocorrência às fls. 16/17 e 19/21
Auto de exibição e apreensão fls. 18.
Processo principal

Boletim de ocorrência às fls. 04/06.
Cópia do mandado de busca e apreensão às fls. 07.
Auto de exibição e apreensão fls. 08/09.

Fotografias às fls. 12/19.
Laudo pericial às fls. 21/37.
Relatório de análise fls. 38/41.
Ofício da Anvisa fls. 100/102.

Recebida a denúncia no dia 11/01/2022, e determinada a citação da ré para responder à acusação às fls. 136/137.

Citada às fls. 144/147, a ré apresentou resposta à acusação às fls. 152/153
Realizada a audiência de instrução, debates e julgamento, foi colhido o depoimento da testemunha André Luis de Moraes, bem como a ré Caroline Pastor Vicente foi interrogada, pelo sistema de gravação audiovisual.

Encerrada a instrução, o Ministério público apresentou as suas alegações finais escritas às fls. 189/196, e requereu que a ação seja julgada procedente, estando a materialidade comprovada e sendo inconteste a autoria. Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, alegou que a pena base deve ser mantida no piso, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase e na terceira fase, não restaram configuradas agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Requereu seja fixado regime inicial fechado, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão de sua execução.

A douta Defesa, em alegações finais escritas às fls. 200/233, alegou que a acusada foi induzida a erro, pois peritos altamente capacitados e equipamentos especializados foram utilizados para se concluir que as substâncias descritas nos rótulos eram totalmente diferentes das utilizadas na composição do produto, não tendo como a ré chegar à conclusão da real composição deste produto. Assim, requereu a desclassificação do delito para sua forma culposa, pela ausência total de dolo e configuração inequívoca do erro de tipo. Em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, sendo concedido à ré o direito de recurso em liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É O RELATO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do relatório de investigação às fls. 02/03, mandado de busca e apreensão às fls. 13, boletim de ocorrência às fls. 16/17 e 19/21 e auto de exibição e apreensão fls. 18 constantes dos autos em apenso (nº 1500380-86.2020. 8.26.0344), pelo boletim de ocorrência às fls. 04/06, cópia do mandado de busca e apreensão às fls. 07, auto de exibição e apreensão fls. 08/09, fotografias às fls. 12/19, laudo pericial às fls. 21/37, relatório de análise fls. 38/41 e ofício da Anvisa fls. 100/102 destes autos, e por toda prova oral coligida no caderno processual sob o crivo do contraditório.

Passo à análise da autoria delitiva.

Em solo policial, às fls. 59, a testemunha Maria Inês Garcia Hermosilla, informou que, na data dos acontecimentos, dia 12 de Fevereiro do ano em fluxo, por volta das 09h30, foi até a Rua Etelvina Teixeira da Silva, número 32, no Bairro Palmital, nesta cidade de Marília, acompanhada do Investigador de Polícia André Luiz de Moraes com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal de Marília, pois, no referido logradouro, a investigada Caroline Pastor Vicente, estaria comercializando produtos emagrecedores não autorizados pela Agência de Vigilância Sanitária. A depoente e o policial André apresentaram o mandado judicial a Caroline, que permitiu a entrada em sua

residência, onde foram encontrados e apreendidos vinte e três frascos vazios, um frasco contendo cápsulas da marca "Fat Red Burner", um frasco contendo cápsulas da marca "Emagry Max", vinte e um frascos contendo cápsulas da marca "Fat Burning Power", e um documento denominado "declaração de conteúdo" de um remetente nomeado "IV Produtos Naturais" destinado à investigada. A depoente conversou com Caroline, que informou que pesava cerca de noventa e sete quilos a cerca de dois anos, e que perdeu trinta quilos utilizando produtos emagrecedores, e que por tal razão chamou a atenção de várias pessoas, passando, então, a vender os produtos emagrecedores que conheceu de maneira autônoma. Salientou que não produz as substâncias, mas apenas as comercializa. A depoente relatou que a investigada Caroline afirmou que compra os produtos de uma pessoa de nome Ivone Aparecida Bezerra, que reside em Valinhos/SP. Por derradeiro, a depoente declinou que a investigada se comprometeu a apresentar os dados bancários e o telefone de Ivone para o melhor esclarecimento dos fatos.

Em depoimento em Juízo, a testemunha André Luis de Moraes, relatou para o Dr. Promotor de Justiça que chegou até a delegacia uma denúncia de que a ré estaria comercializando medicamentos falsificados, então foi solicitado mandado de busca para sua residência. Na busca foram encontrados e apreendidos 23 (vinte três) frascos de medicamentos que estavam sendo comercializados, e que foi alegado pela ré que seriam produtos fisioterápicos. Disse que, na busca, estava junto o delegado Dr. Valdir. Após a apreensão, os medicamentos foram entregues para a perícia, constatando que se tratava de substâncias que dependiam de prescrição médica, e não estavam registrados na Anvisa, na vigilância sanitária. Afirmou que a ré alegou que comprava os produtos de outra pessoa, Ivone, da cidade de Valinhos/SP, pelo WhatsApp, e os revendia, que realizava o pagamento em conta bancária, e a vendedora enviava os produtos, via sedex, para sua residência. Respondeu que a ré disse que tomou os medicamentos, e que tinha emagrecido 30 (trinta) kg, e que as pessoas começaram a perguntar a respeito do medicamento, então teve a ideia de comercializá-los, admitindo assim, que estava revendendo os produtos. Afirmou que foram encontrados, na casa, documentação de origem dos medicamentos. Ao Dr. Defensor finalizou dizendo que a ré estava no momento das diligências, e que ela alegou que os produtos eram fisioterápicos, medicamentos naturais para emagrecimento.

Em interrogatório em Juízo, a ré Caroline Pastor Vicente, relatou que tomou uma série de produtos, que comprou de outra pessoa na época, na cidade de Marília, e emagreceu 35 (trinta e cinco) kg. Comprou como fisioterápicos e não teve nenhum problema, nenhum efeito colateral, e com isso, outras pessoas se interessaram. Disse que obteve o contato da Sra. Ivone, e começou a comprar os produtos para revender, pensando serem fisioterápicos, porque os produtos tinham rótulos, e confiou nas informações. Informou que tomou também, e que a cápsula tinha o cheiro semelhante de chá, de erva. Disse que não entrou em contato com o fabricante, que confiou na vendedora. Para o Dr. Promotor de Justiça respondeu que revendia os produtos, já há um ano e meio, antes da diligência. Ressaltou que nenhuma cliente passou mal, e que não foi informada pela vendedora qual seria o fabricante dos referidos medicamentos, pois pegava em pequenas quantidades, não havendo problemas. Afirmou que cuida de seu filho sozinha, que estava trabalhando para ganhar dinheiro, e não quis prejudicar ninguém. Relatou que, por um bom tempo, foi produtora de eventos do teatro da cidade, e era freelancer. Ressaltou que no rótulo dos produtos havia descrito o conjunto das ervas, que inibia o apetite e que tem por conhecimento que produto fisioterápicos são um composto de ervas. Ao Dr. Defensor disse que a Sra. Ivone nunca informou que os produtos continham as substâncias encontradas na perícia, que eram ilegais, dizia sempre que eram apenas substâncias naturais e que perguntou várias vezes para a vendedora, porém ela sempre mudava de assunto quando questionada. Disse que como leiga, não tinha como saber, apenas olhando, se havia outras substâncias no produtos, teria que ter uma análise, que chegou a abrir algumas cápsulas, que continham um pó verde. Relatou que, pelo que sabe, a Sra. Ivone, tem outras vendedoras, porém não as conhece. Ressaltou que questionou a vendedora por duas vezes sobre os componentes químicos, no entanto, frente às evasivas dela, deveria ter repensado, mas como testou o

medicamento, pensou que não havia problemas. Afirmou que a quantidade de 20 (vinte) potes, daria para um mês ou dois, para a revenda, e que utilizava como argumento de venda, o próprio emagrecimento, as pessoas queriam ajuda, principalmente pessoas que não tinham tempo para ir em uma academia, e que se achavam feias. Concluiu dizendo que revendia os produtos pelo valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais), contendo 30 (trinta) cápsulas em cada frasco, e que os adquiria da Sra. Ivone por em torno de R\$ 90,00 (noventa reais) a R\$ 100,00 (cem reais).

Pois bem.

Em que pese a tese sustentada pela Defesa, a pretensão deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento.

Isso porque, ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática do crime descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Veja-se que o laudo pericial às fls. 21/37 detectou, nos medicamentos apreendidos na residência da ré a presença das seguintes substâncias: "Item A: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA e CAFEÍNA; Item B: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA, SIBUTRAMINA e DIAZEPAM; Item C: POSITIVO para HIDROXICLOROTIAZIDA e SIBUTRAMINA". Ainda, informou que "nenhum dos frascos examinados apresentava indicação de fabricante ou número do responsável junto ao Conselho Regional de Farmácia".

Por fim, informou que "a composição descrita nos rótulos dos frascos examinados não correspondem às substâncias encontradas nas análises químico-farmacêuticas realizadas pelo Núcleo de Análise Instrumental do CEAP".

Às fls. 100/102, o ofício enviado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa informou que "não foram localizados medicamentos registrados em banco de dados da Anvisa com as marcas Fat Red Burner, Emagry Max e Fat Burning Power".

Ainda, atestou que as substâncias sibutramina e diazepam estão sujeitas aos controles da Portaria SVS/MS nº 344/98, estando a primeira prevista na Lista B2 e, a segunda, na Lista B1.

Informou, ainda, que "para realizar quaisquer atividades com estas substâncias, o estabelecimento deve obter Autorização Especial (AE) junto à Anvisa, concedida após avaliação das condições técnicas e sanitárias pertinentes. (...). substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial devem ser guardados sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a responsabilidade do farmacêutico ou químico responsável (...)".

Continuou o ofício explicando que, as substâncias estabelecidas em ambas as Listas, quando registradas na Anvisa, são dispensadas mediante Notificação de Receita, que será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida ao paciente devidamente carimbada.

Ainda, a Portaria SVS/MS nº 344/98 estabelece o veto à compra e venda no mercado interno e externo de substâncias constantes das Listas e de suas atualizações, bem como os seus respectivos medicamentos, por sistemas de reembolso, através de qualquer meio de comunicação, incluindo as vias postal e eletrônica, devendo a importação ser feita por pessoa jurídica, devidamente regularizada, que tenha autorização especial para realizar tal atividade. Por fim, esclareceu que a Lei nº 6.360/1976, em seu artigo 12, proíbe que medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, ainda que importados, sejam industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo antes de registrados na Anvisa.

Veja-se de que não há dúvidas de que a ré tinha em depósito para vender produtos sem registro, sendo exigível no órgão de vigilância sanitária, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização, de procedência ignorada, e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade competente.

A douta Defesa trouxe como argumento defensivo a ocorrência de erro de tipo, não havendo dolo na ação da ré, devendo, portanto, o delito ser desclassificado para a sua modalidade culposa.

Observo, no entanto, em especial pelo interrogatório da ré, que restou configurado o dolo eventual, uma vez que assumiu o risco de produzir o resultado, nos termos do artigo 18, I, do Código Penal. Veja-se que Caroline informou em Juízo que "obteve o

contato da Sra. Ivone, e começou a comprar os produtos para revender, pensando serem fisioterápicos, porque os produtos tinham rótulos”, mas “não entrou em contato com o fabricante, que confiou na vendedora”. Disse, também, que nunca foi informada pela Sra. Ivone, de quem comprava os medicamentos, de que continham substâncias ilegais, que dizia que eram substâncias naturais. Tal assertiva demonstra que a ré previu a possibilidade de as substâncias que estava vendendo não serem aquilo que pareciam ser, por que outra razão teria questionado a vendedora se não por achar que algo poderia estar errado? Veja-se que, segundo a ré, “perguntou várias vezes para a vendedora, porém ela sempre mudava de assunto quando questionada”, tendo dito, inclusive, que “frente às evasivas dela, deveria ter repensado”. Ora, o dolo eventual “é a modalidade em que o agente não quer o resultado, por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo” (Cleber Masson; Código Penal Comentado; 9ª ed., rev., atual., e ampl.; 2021, p. 165). No caso, restou devidamente demonstrado que a ré previu a possibilidade de os produtos que estava revendendo terem composição diversa daquela indicada nos frascos – tanto que questionou diversas vezes a vendedora, além do que tais frascos sequer indicavam o fabricante dos produtos ou o número do responsável junto ao Conselho Regional de Farmácia – e, mesmo assim, continuou a revenda, assumindo o risco de produzir o resultado.

Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MEDICAMENTOS. TIPICIDADE. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. (...). 6. Comprovadas a autoria e a materialidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de contrabando de medicamentos. 7. É pertinente, nesse cenário, a teoria da cegueira deliberada (willful blindness doctrine), que aponta para, no mínimo, o dolo eventual. 8. Considerando os elementos contidos nos autos e revelando-se presentes todos os requisitos para a configuração do dolo eventual, em plena consonância com a teoria da cegueira deliberada, as razões do apelante referentes ao pedido de absolvição não merecem prosperar. 9. “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC 107.409/PE, 1ª Turma do STF, rel. Min. Rosa Weber, un., j. 10.04.2012, DJe-091, 09.05.2012), devendo ser tomados em conta os princípios da necessidade e da eficiência, decompostos nos diferentes elementos previstos no art. 59 do Código Penal, principalmente na censurabilidade da conduta. 10. (...). 13. Apelação criminal improvida” (TRF4, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002815-46.2018.4.04.7002, 8ª TURMA, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19.03.2020).

Saliente-se que a Teoria da Cegueira Deliberada busca criminalizar a conduta do indivíduo que se mantém deliberadamente em estado de ignorância sobre a ilegalidade de seus atos quando perfeitamente possível verificar sua natureza ilícita. In casu, foi exatamente a posição adotada pela ré que, tendo total condição de averiguar a licitude dos produtos que revendia, preferiu acreditar em evasivas dadas pela vendedora, tendo inclusive admitido que devia ter repensado.

Devidamente demonstrado o dolo eventual na conduta da acusada, não há que se falar em desclassificação para o delito em sua modalidade culposa. Por fim, considerando a prova pericial produzida, os relatos seguros dos policiais e a confissão da ré, em solo policial e em Juízo, comprovando a autoria e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a procedência da ação, com condenação do réu é a medida que se impõe.

Em tempo, em atenção à decisão proferida pela Corte Especial do egrégio Superior de Justiça, nos autos de AI no HC 239.363/PR, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considero no cálculo da reprimenda, a pena prevista no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06. Veja-se: “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, DO CP. CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA, PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A intervenção

estatal por meio do Direito Penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 2. É viável a fiscalização judicial da constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais. 3. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do Código Penal. 4. O crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à saúde do pretense usuário do produto evidencia ainda mais a falta de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública. 5. A ausência de relevância penal da conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição da liberdade individual não pode ser excessiva, mas compatível e proporcional à ofensa causada pelo comportamento humano criminoso. 6. Arguição acolhida para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma" (AI no HC n. 239.363/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 10/4/2015).

Explica Renato Brasileiro de Lima:

"Na visão do STJ, impõe-se ao legislador o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. Abre-se, com isso, a possibilidade do controle da constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal. Sendo assim, em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV), é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e ajustar a pena de 'reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa, abstratamente cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, V, do CP, referente ao crime de ter em depósito, para venda, produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada. Isto porque, se este delito for comparado, por exemplo, com o crime de tráfico ilícito de drogas (notoriamente mais grave e cujo bem jurídico também é a saúde pública), percebe-se a total falta de razoabilidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, do CP, sobretudo após a edição da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), que, apesar de ter aumentado a pena mínima de 3 para 5 anos, introduziu a possibilidade de redução da reprimenda, quando aplicável o § 4º do art. 33, de 1/6 a 2/3. Com isso, em inúmeros casos, o esporádico e pequeno traficante pode receber a exígua pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses. E mais, é possível, ainda, sua substituição por restritiva de direitos. De mais a mais, constata-se que a pena mínima cominada ao crime ora em debate excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio doloso simples, é cinco vezes maior que a pena mínima da lesão corporal de natureza grave, enfim, é mais grave do que a do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro, situação que gera gritante desproporcionalidade no sistema penal" (Renato Brasileiro de Lima; Legislação Criminal Especial Comentada; 9ª ed., rev., atual., e ampl.; 2021; p. 349).

Com essas ponderações, passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal.

O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais é apenado com reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase da aplicação da pena, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas. Assim, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, reclusão de 05 (cinco) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase não há incidência de causas de aumento de pena. Entretanto, conforme se infere das certidões e FA de fls. 127/129, a ré não ostenta quaisquer condenações anteriores. Assim, considerando sua primariedade, bem como o fato de não se dedicar a atividade criminosa e sua não vinculação a organização criminosa, aplico o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 na 1/2 (metade), resultando a reprimenda em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima em definitiva. No tocante ao regime de pena, considerando a primariedade da ré, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos dos artigos 33 c/c 59, ambos do Código Penal.

Presentes os requisitos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em: a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca; e b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 01 (um) salário mínimo federal vigente à entidade pública, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal.

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (artigo 77, III, do Código Penal).

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no presente julgamento (artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão condenatória postulada na denúncia para, dando-a como incursa no artigo 273, § 1º-B, I, II, III, IV, V e VI, do Código Penal, condenar a acusada CAROLINE PASTOR VICENTE, já qualificada nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, SUBSTITUÍDA por duas penas restritivas de direito, consistentes em a) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, em local e condições indicados pela Central de Penas e Medidas Alternativas da Comarca; b) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 01 (um) salário mínimo federal vigente à entidade pública, nos termos do artigo 45, § 1º, do Código Penal, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Custas na forma da lei, ressalvados os casos de assistência judiciária gratuita. Diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e, mormente por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá a acusada recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para atendimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.

Expeçam-se os ofícios e as comunicações de prazo.

P.I.C.

Marília, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA